

1500260-67.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500260-67.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500260-67.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158893/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 18459533 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1393/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2158893 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1393/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR MIGUEL BERTANHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

VICTOR MIGUEL BERTANHA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Nove, Bloco nº 09, apartamento 21, bem como em uma área verde ao lado do condomínio Recanto dos pássaros, ambos no Bairro Jardim Odécio Degan, nesta cidade e comarca, o acusado, menor de 21 anos de idade, adquiriu e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 61 porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como maconha, totalizando 188,77 gramas, e 503 porções de cocaína, pesando 198,47 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentada

Segundo restou apurado, o denunciado recebeu e mantinha escondido grande quantidade de maconha e cocaína em área verde e em apartamento, para desenvolver o comércio ilícito de drogas no bairro Jardim Odécio Degan e proximidades.

Na data dos fatos, guardas civis municipais receberam a informação de que havia droga escondida em área verde ao lado do condomínio Recanto dos Pássaros. Chegando no local indicado, os agentes públicos encontraram diversas “trouxinhas” de maconha, prontas para comercialização. Nesse momento, uma transeunte afirmou que os entorpecentes pertenciam a um indivíduo conhecido como “Vi” e indicou seu apartamento.

Em razão disso, os agentes públicos dirigiram-se até o apartamento e foram recepcionados pelo denunciado, que autorizou a entrada dos guardas e informou que havia dinheiro e drogas no imóvel. Durante revista pelo apartamento, foram localizadas no “rack” da televisão 14 porções de maconha e 503 “pinos” de cocaína, já fracionadas, prontas para comercialização. No local também foram encontrados um caderno de anotações e a quantia de R\$2.532,25 em dinheiro.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 141/143).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021 (fls. 149/151).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defesa ofereceram alegações finais em audiência.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando as preliminares levantadas pela Defesa.

Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. Assim, o contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador.

A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Assim, da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP).

Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela prisão.

Então, não houve violação de domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Não bastasse, cabe ainda chamar a atenção que, no caso concreto, havia fundadas suspeitas da prática de crime do tráfico no local a autorizar a ação da guarda civil municipal.

De fato, revelou a prova oral que a diligência policial questionada pela Defesa foi precedida de encontro de drogas em terreno ao lado do condomínio. Na data dos fatos, guardas civis municipais receberam denúncia anônima e encontraram entorpecentes numa área verde (trouxinhas de maconha). Após, uma pessoa que não quis se identificar, moradora do local e incomodada com a ação dos traficantes, indicou que aquela droga seria da pessoa de apelido Vi e apontou o apartamento que ele ocupava.

Em razão disso, os agentes públicos foram até o apartamento e lá foram recepcionados pelo acusado, o qual franqueou a entrada e assumiu a existência de dinheiro e drogas no interior daquele imóvel. Naquele local, os guardas civis apreenderam um caderno de anotações, a quantia de R\$2.532,25 em dinheiro ao lado de um colchão, 14 porções de maconha e 503 pinos de cocaína no rack de televisão indicado pelo denunciado.

Em resumo, o réu estava em comportamento típico de tráfico, mas foi interrompido pela ação da guarda municipal, havendo prisão em flagrante. Aliás, o acusado confirmou em Juízo que trabalhava para terceiros guardando drogas e dinheiro para quitar uma dívida.

Os elementos trazidos pelos guardas civis municipais corroboraram a fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico no imóvel residencial em que o denunciado foi preso, com o encontro de entorpecentes e produto da traficância, de crime considerado permanente, o que justificou a busca e apreensão sem mandado judicial.

Havendo, portanto, sérios e concretos indicativos da prática de tráfico no local dos fatos, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 280):

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não é outro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, a saber:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial”. (STF, HC 177923,

Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021).

“Agravamento regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Exceção. Situação de flagrante delito. Controvérsia acerca do ingresso de policiais no domicílio (...). 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE nº 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental não provido”. (STF, HC 197268 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (STF, ARE 1312140 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF, HC 198582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

As demais preliminares levantadas pela Defensoria Pública se confundem com o mérito da ação penal.

Não havendo preliminares pendentes de apreciação, no mérito o pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo com resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 30/33 e 99/101), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado disse que não é traficante, sendo apenas usuário de maconha. Não tem antecedentes criminais. Foi convidado por um homem chamado Abner Silva, que já tem passagens pela polícia e tem apelido de "Gordinho", para um churrasco no prédio onde ele mora, no Recanto dos Pássaros, local onde houve a apreensão dos entorpecentes. O denunciado resolveu ir no churrasco junto com sua namorada Letícia para comemorar o dia dos namorados. Fizeram um churrasco na área externa do prédio, um "rancho". Como já estava bastante tarde da noite, pediu para dormir no apartamento de Abner Silva, onde ele mora junto com a esposa dele e um filho de cinco anos, de nome Davi. O acusado não sabe o nome da esposa de Abner Silva, mas sabe que ela esteve presa. No apartamento do Abner mora também o "neguinho", cujo nome seria Gabriel, que parece ter antecedentes criminais. O apartamento tem dois quartos, sendo que um era ocupado por Abner e outro por Gabriel. Ele dormiu na sala, em um colchão, e admite que já dormiu naquele apartamento umas cinco vezes e iria ali apenas para fumar um cigarro de maconha. Pela manhã, por volta das 08 horas, Abner falou que iria sair para comprar café da manhã. Abner saiu junto com sua mulher e seu filho, bem como com Gabriel. O acusado ficou sozinho no apartamento e foi informado por Abner que ele tinha apenas 25 gramas de maconha no apartamento para uso próprio. O denunciado não chegou a ver a maconha de Abner. Tinha em sua posse apenas uma pequena porção de maconha suficiente para fazer dois cigarros, para uso próprio. Não sabia que tinha grande quantidade de pinos de cocaína e maconha no apartamento, bem como não sabia da existência de dinheiro. Quando Abner saiu, ele deixou o quarto dele trancado, mas deixou a referida chave no rack. Logo que eles saíram, o acusado ouviu batidas na porta e foi atender, eram os guardas municipais que pediram para dar uma olhada no apartamento. O denunciado autorizou e já foi logo dizendo da existência de sua maconha e aquela citada por Abner. Os guardas pediram para entrar no quarto que estava trancado e solicitaram a chave. Pegou a chave e deu a eles. Eles entraram no quarto e encontraram o dinheiro no pé da cama do Abner e a droga no guarda-roupas. Depois do encontro da droga foi preso. Não sabia daquele entorpecente, tem uma filha de um ano e quatro meses com Letícia. Mora com sua mãe no bairro CECAP e atualmente está desempregado. O denunciado alega que é conhecido por "Vitinho", e não por "Vi" (fls. 06/07).

Na fase do contraditório, todavia, o acusado modificou sua versão a respeito dos fatos.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu disse que tem 19 anos. Tem uma esposa e uma filha. Seu irmão trabalhava com pintura, mas devido à pandemia não havia mais bicos. Morou com sua mãe. Devido a uma dívida, estava sendo ameaçado, não queria prejudicar sua família, surgiu uma proposta de frequentar o apartamento. Os donos falaram que ele tinha uma dívida de drogas. Falaram que ele tinha que frequentar a casa e cuidar das drogas até morrer a dívida. Fazia um mês que frequentava aquela casa. A polícia invadiu a casa e falaram que era uma denúncia. Não falou onde estavam as drogas. Não falou que era gerente. Foi tirado do local. Havia drogas, era cocaína, não havia maconha. O dono da casa estava lá antes dele ser preso. Não sabia da existência de dinheiro perto do colchão. As pessoas falaram que não tinha hora pra voltar. Sua sogra iria ajudar uma outra casa. Tem muitas desavenças com seu sogro. Iria alugar um outro imóvel. Não alugou aquele apartamento. Não conhecia os guardas. Foi cuidar do local por conta da dívida. Acredita que a denúncia foi feita por algum morador incomodado com a ação dos traficantes que ali guardavam entorpecentes. Teve passagem por tráfico quando era menor de idade. O tráfico ocorre muito do lado de fora do condomínio. Confirmou que estava frequentando o local há cerca de um mês como forma de vigília das drogas e que iria quitar uma dívida. Iria alugar uma casa nas proximidades. O apartamento não tinha água, luz, estava abandonado. Está arrependido. A testemunha de defesa se equivocou quanto aos fatos narrados. Sabia que o imóvel era usado para guarda de dinheiro e drogas, mas não sabia onde isso ficava, os donos não disseram a ele o local do esconderijo. Só

os donos frequentavam ali (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

O guarda municipal Danilo Amaral Luna Soliz disse que o bairro é muito conhecido nos meios policiais. Receberam uma denúncia de drogas guardadas ao lado do condomínio, numa área verde. Foram lá e acharam pouca quantidade de maconha. Iriam apresentar o que encontraram no distrito policial. Foi aí que uma senhora veio, apontou o apartamento e o bloco de quem seria o dono daquela droga. Ela foi muito discreta e indicou o apelido da pessoa como sendo Vi. Ela disse que esse indivíduo seria o gerente e que lá no apartamento havia mais entorpecentes. Pediram apoio de outras viaturas. Bateram na porta. Assim que o réu abriu a porta e viu a presença da guarda municipal ele disse que perdeu. Depois de perguntarem a respeito das drogas, ele apontou onde elas estavam no apartamento, indicando a região do rack. No colchão havia mais de dois mil reais em dinheiro trocado, era quantia proveniente da venda. A princípio, ele disse que só dormia no apartamento, mas depois assumiu que tomava conta das drogas e soltava para outros moleques venderem. Deram voz de prisão. O acusado confessou a gerência só depois, a princípio ele falou que só estava dormindo. O local do pasto até o bloco do apartamento dá em torno de cinquenta metros, dá cerca de dois blocos. Foram duas viaturas. Não conhecia o acusado. No chão havia um colchão. Deu pra perceber que havia roupas do acusado, o local era bem sujo. As drogas já estavam divididas, não havia peneira, não havia petrecho, já estava pronta. Só o acusado estava lá. A namorada e família dela apareceram depois e disseram que não sabia que ele fazia aquilo. Havia armários na cozinha, rack e uma televisão. Deu a entender que o acusado contava o dinheiro antes da abordagem. A ocorrência de gerência é comum naquele local, há uma divisão de turnos entre os traficantes (mídia).

O guarda municipal Tiago da Silva Martins contou que, no dia da ocorrência, receberam denúncia anônima de droga existente numa área verde ao lado do condomínio. Encontraram na moita uma sacola branca contendo trouxinhas de maconha. Uma senhora passou e disse que a droga era de Vi, indicando o apartamento dele. Chamaram apoio. Foram até o apartamento e lá foram recebidos pelo réu. De pronto ele disse que perdeu e confirmou a existência de drogas e dinheiro. A entrada foi franqueada. Havia dinheiro ao lado do colchão e havia cocaína no rack da sala. Apresentaram a ocorrência no plantão policial. Indagado, o imputado deu várias versões. Ele chegou a falar de início que nada era dele, que ele só dormia ali e mais pessoas dormiram naquele dia. As drogas estavam expostas no rack, foi ele que indicou o local. O acusado falou que guardava os entorpecentes para outra pessoa, não foi dado o nome. Não conhecia o réu de outras abordagens. Encontraram mais de dois mil reais em dinheiro, havia vários montes de dinheiro ao lado do colchão, era visível. A namorada do acusado compareceu na delegacia (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a guarda municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não

mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10)(...) (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foi ouvida uma testemunhas de defesa.

A testemunha Juliana Alves disse que mora dentro do condomínio Recanto dos Pássaros. Conhece o acusado daquele local. Não sabe o apartamento e o bloco que ele mora. O réu foi detido no apartamento que ele residia, era lá que ele morava. Na época o réu não trabalhava. Só ficou sabendo do envolvimento dele com o tráfico quando era menor de idade. Não ficou sabendo de comentários dos vizinhos. Sabia que ele guardava dinheiro por conta de dívida de drogas quando ele era menor de idade. Já ouviu falar de Abner, nunca o viu pessoalmente. Não sabe dizer se Abner mora ali. Já ouviu falar de neguinho Gabriel, mas não o conhece. Desde a adolescência o acusado tem problemas com o tráfico. Quando ele era menor de idade ele ficou com dívidas, ele parou de traficar. Ficou sabendo que ele tinha dinheiro para pagar essa dívida de drogas. Conhece o acusado e a família dele. Não foi visita-lo na penitenciária. Sabe que ele guardava dinheiro para quitar uma dívida. Leticia é a mulher dele e Joice é uma conhecida. Não sabe o valor da dívida do réu com drogas. Não sabe para quem ele devia. Não ficou sabendo de gerência envolvendo o réu. Fazia dois meses que ele morava no apartamento. Ele iria terminar de pagar a dívida e parar com isso. Sabe que Leticia ia morar ali, na época da prisão eles não moravam juntos. O acusado alugou o apartamento dois meses antes da prisão e ele iria morar com a família. O réu não trabalhava (mídia).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, guardas municipais receberam a informação de que havia droga escondida em uma área verde ao lado do condomínio Recanto dos Pássaros, local conhecido nos meios policiais pela traficância ilícita. No sítio indicado, eles encontraram diversas "trouxinhas" de maconha, prontas para comercialização, dentro de um saco plástico. Nesse momento, uma senhora se aproximou, afirmou que os entorpecentes pertenciam a um indivíduo conhecido como "Vi" e indicou o seu apartamento.

Em razão das fundadas razões e com o apoio de outras viaturas, os agentes públicos foram recepcionados pelo réu no apartamento, o qual de pronto confirmou a existência de dinheiro e drogas no interior do imóvel. A entrada foi franqueada. O acusado indicou o rack e lá foram encontradas 14 porções de maconha e 503 pinos de

cocaína, já fracionadas, prontas para comercialização. Perto de um colchão foi localizada a quantia de R\$2.532,25 em dinheiro, em notas fracionadas, assim como um caderno de anotações.

Indagado, apesar da hesitação inicial, ele confirmou o seu envolvimento na traficância ilícita. No momento da prisão não havia mais pessoas no interior do apartamento, existindo objetos pessoais do acusado naquele local.

A testemunha de defesa, moradora do condomínio, confirmou a morada do réu no apartamento desde dois meses antes da prisão e mencionou o envolvimento dele com ato infracional análogo ao tráfico de drogas quando da sua menoridade.

Assim, respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado, haja vista a quantidade, natureza, diversidade e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína e maconha), a delação anônima apontando o apelido e o apartamento do acusado, as circunstâncias da prisão, o encontro de vasta quantia em dinheiro sem justificativa, assim como o depoimento incriminador dos guardas civis municipais, tudo a apontar o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de drogas.

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente

(art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos guardas civis municipais para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de Defesa que corroborassem a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que efetuaram a abordagem e o prenderam em flagrante delito.

O testemunho de Juliana Alves incrimina o acusado ao noticiar a morada do acusado no apartamento por dois meses e que lá realmente havia dinheiro para fins de pagamento de uma dívida de drogas. Apesar dela relatar o não envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de drogas após a sua maioridade, o fato é que os guardas civis municipais localizaram vasta quantia de drogas no imóvel de responsabilidade do réu.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Não prospera a tese de desclassificação para o artigo 37 da Lei de Drogas (informante colaborador). Apesar do acusado alegar exercer apenas a função de "olheiro", as provas colhidas demonstram a ligação com o hediondo comércio, atuando ativamente no tráfico ilícito de drogas, participando diretamente da própria execução do crime (em divisão de tarefas com terceiros não identificados), o que não se confunde com a conduta prevista no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, de mero prestador de informações.

Como conclui Cleber Masson:

"Em verdade, nem toda espécie de colaboração é englobada pelo art. 37 da Lei de Drogas. De fato, a "colaboração material" normalmente acarreta em verdadeiro

auxílio ao narcotráfico, fazendo com que o “colaborador” seja considerado partícipe do tráfico de drogas. Além disso, também é possível cogitar da participação no tráfico de drogas pela “colaboração moral”, quando então o sujeito será alcançado pela norma de extensão pessoal contida no art. 29, caput, do Código Penal, por ter instigado ou induzido o autor deste delito. Finalmente, a colaboração mediante financiamento ou custeio ao tráfico de drogas pode configurar o delito tipificado no art. 36 da Lei 11.343/2006” (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, observo que o réu possui histórico de atos infracionais quando da sua menoridade (fls. 42/43 - autos nº 1504268-09.2018.8.26.0320 e execução nº 0012481-78.2018.8.26.0320), tendo cumprido medidas socioeducativas e contando com passagem pela Vara da Infância e Juventude local, fato assumido pelo réu quando interrogado, o que denota dedicação à atividade criminosa com o encontro de 61 porções de maconha totalizando 188 gramas e 503 pinos de cocaína pesando 198 gramas, já fracionadas, prontas para comercialização assim como a importância de R\$2.532,25 em dinheiro, sem qualquer justificativa, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como pelo fato de que o paciente já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 604.121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

"(...) - O ora paciente conta com condenação anterior à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para afastar a redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa (...) Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Apesar da Defesa afirmar que o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a utilização de atos infracionais não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, a questão não é pacífica e encontra divergência no âmbito das duas turmas da Suprema Corte, em conformidade com os julgados que cito abaixo:

"Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021).

"Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, RHC 190434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 12-11-2021 PUBLIC 16-11-2021).

"Habeas corpus. (...) Redutor. Tráfico privilegiado. Existência de ato infracional. (...) 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, "[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (...) (STF, HC 195540, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021).

No mesmo sentido, confira-se: STF, HC 206922, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 24/09/2021, publicado em 27/09/2021.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão (61 porções de maconha totalizando 188 gramas e 503 pinos de cocaína pesando 198 gramas), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VICTOR MIGUEL BERTANHA, qualificado nos autos, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, eis que fruto do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA